

- **Expediente N.º: EXP202401934**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: **A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante) 02/01/2024 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD). La reclamación se dirige contra **GAFAS EN RED DE ÓPTICAS S.L.** (en adelante GAFAS EN RED), con NIF **B73833758**, pero en las alegaciones de 11/07/2024 a este procedimiento sancionador, su representante legal informa de que denominación de la empresa es a partir del 01/01/2024 **SUPERVISTA OPTICS SLU**.

Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes:

La recepción de comunicaciones electrónicas comerciales en la dirección electrónica ***USUARIO.1@gmail.com, siendo la última de fecha 12/12/2023, tras la confirmación el 24/05/23 por GAFAS EN RED de la recepción oposición/supresión de la parte reclamante a recibir comunicaciones comerciales.

Junto a la notificación se aporta copia del mensaje de 24/05/23 de GAFAS EN RED, que confirma la baja solicitada, así como copia del mensaje de 12/12/2023, en el que GAFAS EN RED ofrece una nueva revisión de la vista a la parte reclamante.

El correo electrónico remitido por GAFAS EN RED a la parte reclamante dice lo siguiente:

“Estimado cliente, han pasado aproximadamente 2 años desde que adquiriste unas gafas con nosotros.

¿Sabías que, a pesar del tiempo transcurrido, como cliente de gafas.es tienes derecho a realizar una revisión de la vista gratuita?

Dado que la agudeza visual puede cambiar significativamente durante el transcurso de dos años, queremos recordarte hoy que estás invitado/a a realizar una revisión de vista gratuita con nosotros.

¿Quizás ya lo has notado por ti mismo/a? Por ejemplo, ¿has experimentado un deslumbramiento pronunciado por las luces del tráfico mientras conduces de noche? En caso afirmativo, ¡esto sería una clara señal de que tu agudeza visual ha cambiado!.

Además, con las gafas que compraste con nosotros, siempre tienes derecho a un ajuste de gafas y revisión de la vista gratis y sin compromiso. El ajuste de gafas incluye: - Limpieza, atornillado y ajuste de la montura para una mayor comodidad. -

Revisión de la vista profesional gratuita para evaluar el estado actual de tus lentes y si tu graduación ha cambiado. RESERVA UN AJUSTE DE GAFAS Y REVISIÓN DE LA VISTA GRATUITOS”

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación el 02/02/2024 a GAFAS EN RED, para que procediese a su análisis e informase a la AEPD en el plazo de un mes de las acciones llevadas a cabo, para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 13/02/2023, como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. No se ha recibido respuesta a este escrito de traslado.

TERCERO: Con fecha 02/04/2024, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

CUARTO: El 28/05/2024, la Directora de la AEPD acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, por la presunta infracción del Artículo 21 de la LSSI, tipificada en el Artículo 38.4.d) de la LSSI.

QUINTO: Notificado el citado acuerdo de inicio el 29/05/2024 electrónicamente conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), tiene lugar el acuse de recibo el 07/06/2024.

SEXTO: El 04/07/2024 SUPERVISTA AG, como propietaria al 100% de SUPERVISTA OPTICS SLU (antes llamada GAFAS EN RED), presenta una solicitud de prórroga hasta el 12 de julio de 2024 para este expediente. SUPERVISTA AG es una S.A. con domicilio en Alemania, Königs Wusterhausen SIEMENSSTRABE 2, 15711 CP.

En la solicitud de ampliación de un nuevo plazo para las alegaciones, además de ser extemporánea, tampoco se acredita documentalmente que el firmante de SUPERVISTA AG ostente la representación SUPERVISTA S.L.U.

SÉPTIMO: En su escrito de alegaciones de 11/07/2024 SUPERVISTA OPTICS SLU (ESPAÑA), indica primero, que a partir del 01/01/2024 GAFAS EN RED) se ha producido un cambio de denominación social, pasando a llamarse SUPERVISTA OPTICS SLU; y, a continuación, manifiesta en síntesis que la parte reclamante era cliente de GAFAS EN RED y tras oponerse a recibir mensajes el 24/07/2023, fue incluida en una lista negra de marketing, por lo que no volvió a recibir comunicaciones comerciales electrónicas a partir de esa fecha. No obstante, sus datos, en tanto que cliente y usuaria, siguieron siendo almacenados conforme a las exigencias legales.

Alega también que el 12/12/2023, remitió GAFAS EN RED a la parte reclamante un mensaje para una revisión gratuita de las gafas adquiridas, por no haber expirado aún el plazo de garantía y que se trataba de un correo electrónico de servicio y no

comercial, porque el artículo 21.2 de la LSSI autoriza el envío de comunicaciones comerciales cuando exista una relación contractual previa y la comunicación se refiera al producto adquirido.

Concluye en las alegaciones que no existe infracción, ni intencionalidad, ni reincidencia en este caso y que la propuesta de sanción de una multa de veinte mil euros (20.000 €) es completamente desproporcionada, incluso si se presupone intencionalidad y reincidencia.

Alega también la sentencia del TJUE (EuGH/TJCE C-300/21 de 04.05.2023), según la cual debe examinarse si se ha producido un daño a la persona afectada, que tiene lugar si los datos del interesado se han divulgado a terceros no autorizados. Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 84 del RGPD, sobre la posibilidad de obtener automáticamente una indemnización por daños y perjuicios ante los tribunales, basándose en una infracción del RGPD.

OCTAVO: En la Propuesta de Resolución de 07/08/2024, se valoran las alegaciones de al Acuerdo de inicio presentadas por GAFAS EN RED el 11/07/2024 del siguiente modo:

GAFAS EN RED alega que la parte reclamante era cliente y que tras ejercer su derecho de oposición a las comunicaciones publicitarias 24/05/2023, la parte reclamante fue incluida en una lista negra de marketing, por lo que no volvió a recibir comunicaciones comerciales electrónicas a partir de esa fecha. Considera GAFAS EN RED que el mensaje remitido tiene a su cliente, no tiene naturaleza comercial, al tratarse de un servicio ofrecido a su cliente, en consonancia con el artículo 21.2 de la LSSI.

Al respecto hay que reiterar la definición de comunicación comercial del ANEXO apartado f) de la LSSI como: “toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.” De conformidad con esta definición, tanto la carta, como el correo electrónico remitidos por GAFAS EN RED tienen el carácter de comunicación comercial.

Con respecto al artículo 21.2 párrafo 1º de la LSSI alegado por GAFAS EN RED, la remisión de comunicaciones publicitarias sería sólo de aplicación en tanto que el interesado no ha ejercido su derecho de oposición, previsto en el párrafo 2º, del propio artículo 21.2 de la LSSI.

Como la parte reclamante ha ejercido su derecho oposición a seguir recibiendo mensajes publicitarios el 24/05/2023 y GAFAS EN RED ha hecho acuse de recibo de esta solicitud en esa misma fecha, las comunicaciones posteriores de GAFAS EN RED han tenido lugar en contra de la voluntad manifestada por la parte reclamante.

El artículo 21 la LSSI prohíbe así expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas y también las realizadas en contra del derecho de oposición del interesado, debidamente manifestado.

Alega también GAFAS EN RED que no existe infracción, ni intencionalidad, ni reincidencia en este caso y la propuesta de sanción de veinte mil euros (20.000 €) multa es completamente desproporcionada, incluso si se presupone intencionalidad y reincidencia.

En cuanto a la inexistencia de infracción alegada, el artículo 38.4 apartado d) de la LSSI califica como infracción leve el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de la LSSI, como es el caso. El envío de comunicaciones publicitarias a sabiendas de la voluntad contraria manifestada por el interesado es una infracción leve según la LSSI, toda vez que GAFAS EN RED era conocedora de la oposición de la parte reclamante, a quien remitió un correo electrónico de confirmación.

En cuanto a la alegación de ausencia de proporcionalidad de la sanción, hay que señalar los 20.000€ propuestos para la sanción se encuentran en nivel medio del intervalo de multas de hasta un máximo 30.000€, conforme a lo estipulado para las infracciones leves por el artículo 39.1 c) de la LSSI.

En cuanto a la alegación de ausencia de reincidencia, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo LRJSP), en su artículo 29.3 apartado d) (proporcionalidad de las sanciones para la potestad sancionadora) regula este aspecto del modo siguiente:

*“La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:
(...)*

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.”

Existe ya una resolución firme del procedimiento sancionador de la propia AEPD (PS/00076/2024), por la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza por parte de GAFAS EN RED; la propuesta de sanción del PS/00076/2024 fue inicialmente de 10.000€ y la sanción finalmente pagada se redujo 6.000€, pero sólo como resultado de las reducciones del 20% por reconocimiento de responsabilidad y del 20% por renuncia a la vía administrativa (reducción total del 40% de la sanción como suma de ambos conceptos).

Por ello, resulta procedente agravar la propuesta de sanción, cumpliendo así con el principio de proporcionalidad, al agravarse el incumplimiento, de conformidad con el artículo 29.3 apartado d) de la LRJSP.

En cuanto a la alegación de falta de intencionalidad como agravante, hay que señalar que GAFAS EN RED, ignora el deseo legítimamente manifestado por la parte reclamante a quien envió incluso envió un e-mail de confirmación de su derecho de oposición, demostrando con ello una voluntad cualificada de contrariar su voluntad de no recibir envíos publicitarios, al enviarle un correo electrónico y también correo postal, ambos con análogo contenido promocional.

En la gradación de la sanción, la aplicación de los agravantes de intencionalidad y de reincidencia son correctas en cuanto a la aplicación del principio de proporcionalidad en la sanción, tomando como punto de partida la sanción anteriormente propuesta (PS/00076/2024), junto con los dos agravantes descritos y debidamente acreditados.

Alega GAFAS EN RED en su defensa la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (EuGH/TJCE C-300/21 de 04.05.2023), que exigiría la existencia de un daño a la persona afectada como requisito previo para la sanción y que sólo tendría lugar si los datos del interesado se han divulgado a terceros no autorizados.

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 84 del RGPD, a saber, la posibilidad de obtener automáticamente una indemnización por daños y perjuicios ante los tribunales, basándose en una infracción del RGPD. Esta cuestión litigiosa y su solución en la sentencia indicada, no tiene nada que ver con el presente procedimiento, que tiene su fundamento en una infracción de naturaleza administrativa de la LSSI, y no en los requisitos necesarios para una posible indemnización por daños y perjuicios ante los tribunales civiles por incumplimiento del RGPD, por lo que la jurisprudencia y doctrina resultantes no serían de aplicación para el caso en cuestión.

NOVENO: En la propuesta de resolución, se confirma la sanción inicial del Acuerdo de Inicio y proponiendo que se sancione a **SUPERVISTA OPTICS SLU** (hasta el 31/12/2023 bajo el nombre de **GAFAS EN RED DE ÓPTICAS, S.L.**), con **multa de veinte mil euros (20.000€)** por la infracción del Artículo 21 de la LSSI, tipificada en el Artículo 38.4.d) de la LSSI.

El 07/08/2024 la AEPD se notificó a **SUPERVISTA OPTICS SLU**, con acuse de recibo de 08/08/2024, la propuesta de resolución, concediéndoles un plazo de 10 días para realizar nuevas alegaciones, sin que haya aportado alegación alguna hasta la fecha.

De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La parte reclamante ha sido cliente de GAFAS EN RED (a partir de 01/01/2024 se denomina SUPERVISTA OPTICS SLU).

SEGUNDO: El 24/05/23 la parte reclamante ejerció ante GAFAS EN RED su derecho de oposición para la recepción de comunicaciones publicitarias. GAFAS EN RED comunicó en la misma fecha la baja de los datos de la parte reclamante.

TERCERO: El 12/12/2023 recibe la parte reclamante en su dirección de correo electrónico de GAFAS EN RED ***USUARIO@gmail.com, nuevamente una comunicación comercial para la revisión de la vista y la graduación de nuevas gafas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI) y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

Por último, la Disposición adicional cuarta "Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes" establece que: *"Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes."*

II

Cuestiones previas

Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas, mediante correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes

Con carácter general, prohíbe la LSSI las comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas, partiendo de un concepto de comunicación comercial que se califica como servicio de la sociedad de la información y que se define en su Anexo de la siguiente manera:

"f) Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica".

El concepto de comunicación comercial, de acuerdo con la definición recogida en el Anexo f), párrafo primero de la LSSI, engloba todas las formas de comunicaciones destinadas a promocionar directa o indirectamente bienes, servicios o la imagen de

una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Por otro lado, la LSSI en su Anexo a) define *“Servicio de la Sociedad de la Información”* como *“todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario”*.

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios”.

La definición de prestador del servicio se contiene en el apartado c) del Anexo de la citada norma que considera como tal la *“persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información”*.

Añade el referido apartado que el envío de comunicaciones comerciales es un servicio de la sociedad de la información, siempre que represente una actividad económica.

Según el apartado d) del citado Anexo, destinatario es la *“persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información”*

De lo anterior se deduce que, cuando la comunicación comercial no reúne los requisitos que requiere el concepto de Servicios de la Sociedad de la Información, pierde el carácter de comunicación comercial.

En este sentido el párrafo segundo del Anexo f) de la LSSI señala dos supuestos, que no tendrán, a los efectos de esta Ley, la consideración de comunicación comercial:

- a) los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, y,
- b) las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica.

El Artículo 21 de la LSSI, regula las condiciones de las comunicaciones publicitarias del siguiente modo (se subraya lo relevante para el caso):

Artículo 21

“1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.”

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones

comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección."

El artículo 21.1 la LSSI prohíbe así expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas, con la sola

la excepción prevista en artículo 21.2 de la LSSI, que autoriza el envío de comunicaciones comerciales cuando exista una relación contractual previa, y exclusivamente para comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los contratados inicialmente por el cliente.

Se denomina "*spam*" a todo tipo de comunicación no solicitada, realizada por vía electrónica y cuyo fin es ofertar, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o empresa.

El envío de mensajes comerciales, sin el consentimiento previo o habiéndose ejercido el derecho de oposición, está prohibido por la legislación española, y más aún cuando se realiza en forma masiva e indiscriminada. El bajo coste de los envíos de correos electrónicos vía Internet o mediante telefonía móvil (SMS y MMS), su posible anonimato, la velocidad y volumen de las transmisiones han favorecido que esta práctica se realice de forma abusiva e indiscriminada.

III

Obligación incumplida Artículo 21 de la LSSI

Los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una infracción, imputable a la parte reclamada, por vulneración del artículo 21 de la LSSI.

De conformidad con las evidencias disponibles, GAFAS EN RED remite el 12/12/2023 un correo electrónico comercial al correo electrónico de la parte reclamante ***USUARIO.1@gmail.com, a pesar de haber confirmado GAFAS EN RED mediante mensaje de 24/05/23 la baja de sus bases de datos a efectos de comunicaciones comerciales, en respuesta a la solicitud de la parte reclamante.

GAFAS EN RED ostenta la condición de prestador del servicio, al tratarse de una persona jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información (Anexo apartado c) de la LSSI) que realiza comunicación comercial para la promoción, directa

o indirecta, de la imagen o de sus bienes o servicios de su empresa, (definición Anexo f) de la LSSI). El servicio ofrecido es la revisión gratuita de la vista, un servicio no remunerado, pero que GAFAS EN RED realiza en el marco de su actividad comercial, en su condición de prestador de servicios de óptica (venta de gafas, etc.) para promoción de sus bienes y servicios.

GAFAS EN RED habría remitido un correo electrónico con comunicación publicitaria, conociendo la oposición del destinatario desde mayo de 2023, a pesar de que GAFAS EN RED comunica en esa fecha la eliminación de los datos personales a la parte reclamante.

Con el envío de la comunicación comercial sin el consentimiento de la parte reclamante, que ha ejercido con carácter previo al envío su derecho de oposición, GAFAS EN RED habría infringido el artículo 21 de la LSSI, que exige para estos supuestos el consentimiento del destinatario y prohíbe el envío de comunicaciones comerciales habiéndose ejercido el derecho de oposición.

IV

Tipificación de la infracción

De este modo, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, fuera del supuesto excepcional del artículo 21.2 de la LSSI, puede constituir una infracción leve o grave de la LSSI.

El Título VII de la LSSI bajo la rúbrica “*Infracciones y sanciones*” contiene el régimen sancionador aplicable en caso de que se produzca alguna de las infracciones contenidas en el cuadro de infracciones que en el mismo se recoge. En concreto, el artículo 37 especifica que “*los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente Ley les sea de aplicación.*”

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la LSSI, se consideran infracciones graves y leves las siguientes (se subraya la parte aplicable al caso):

“4. Son infracciones leves:

d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”.

A la vista de los hechos probados, el incumplimiento del artículo 21 de la LSSI constituye en los términos indicados por el citado artículo 38.4.d), una infracción leve en este caso, al tratarse de un envío individual de una comunicación publicitaria o promocional por correo electrónico, sin consentimiento del interesado.

V Propuesta de sanción

Esta infracción del artículo 21, al calificarse como leve, puede ser sancionada con multa de hasta 30.000€, de acuerdo con el artículo 39.1 c) de la LSSI que estipula lo siguiente (se subraya la parte aplicable al caso):

“1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves, sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años.

b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros.

c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros.”

Asimismo, de conformidad con las evidencias de las que se dispone, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios que establece el artículo 40 de la LSSI:

“La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios (se subraya los criterios aplicados):

a) La existencia de intencionalidad.

b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.

e) Los beneficios obtenidos por la infracción.

f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.

g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.”

-La existencia de intencionalidad (apartado a), ya que la parte reclamante había solicitado que no volvieran a enviarle más comunicaciones comerciales y la entidad reclamada había acusado recibo de dicha solicitud, confirmando que había sido atendida, y pese a ello, después ha vuelto a enviarle mensajes publicitarios.

-Al existir una resolución firme del procedimiento sancionador de la AEPD (PS/00076/2024), por la comisión por parte de GAFAS EN RED de una infracción de la misma naturaleza en el mismo año, se aplica también el agravante de reincidencia (apartado c).

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera adecuado mantener la propuesta de sanción del acuerdo de inicio, de una multa administrativa de **veinte mil euros (20.000€)**.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE**:

PRIMERO: IMPONER a **SUPERVISTA OPTICS SLU** (hasta el 31/12/2023 bajo la denominación de GAFAS EN RED DE ÓPTICAS, S.L.), con NIF **B73833758**, por una infracción del Artículo 21 de la LSSI, tipificada en el Artículo 38.4.d) de la LSSI, una multa de **veinte mil euros (20.000 euros)**.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **SUPERVISTA OPTICS SLU**.

TERCERO: Esta resolución será ejecutiva una vez finalice el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición (un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución) sin que el interesado haya hecho uso de esta facultad. Se advierte al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta restringida nº **IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX)**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.. En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos